

1502818-33.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Nobrega Feitosa

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... que estava naquele local promovendo o tráfico ilegal de drogas, aduzindo inclusive que havia passado cerca de 6 anos encarcerado, cumprindo pena pela prática de dois crimes de tráfico ilegal de drogas, e que saiu recentemente da cadeia, estava promovendo o tráfico naquele local percebendo cerca de R\$ 300,00 ao dia. Acrescenta que na delegacia de polícia, ao ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n.º 01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502818-33.2021.8.26.0544 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1502818-33.2021.8.26.0544 - Controle n.º 2391/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310826/2021 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 21398625 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3656/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2310826 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEEFERSON DA LUZ THEODORO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Nobrega Feitosa

Vistos.

JEEFERSON DA LUZ THEODORO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções cominadas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 15 de novembro de 2021, por volta de 17h40min, na Rua Rancharia, 49 Vila Nita, nesta cidade e comarca, estaria guardando e traria consigo, para supostos fins de entrega a terceiros, as seguintes drogas: 47 papелotes de maconha, pesando, aproximadamente, 132g; 170 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 153g e 90 pedras de crack, pesando, aproximadamente 23g; substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a apreensão de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e

cinco reais) em dinheiro, nos termos da denúncia de fls. 64/65.

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fl. 66). O réu foi citado (fls. 85/87), tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 92/93). Ante a ausência de hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fl. 94), realizou-se a instrução criminal, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e, após, o réu foi interrogado. Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a procedência do pedido condenatório, assim como pleiteou pela legalidade da prisão efetuada. Por sua vez, a Defensoria Pública pleiteou, resumidamente, a ilegitimidade da prisão em decorrência de provas ilícitas, assim como, requereu, subsidiariamente, a aplicação de pena em seu patamar mínimo, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e regime diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico a inexistência de quaisquer nulidades, bem como não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que passo à apreciação do mérito.

Entretanto, insta salientar que a legalidade da prisão do acusado já foi devidamente fundamentada quando da realização da análise do flagrante delito (fls. 43/45). Entretanto, ainda que se sustente a ilegalidade da prisão, em decorrência de provas ilícitas (patrulhamento preventivo efetuado pela guarda municipal), neste caso urge salientar que houve a incidência do flagrante compulsório, ante à constatação fortuita de sua ocorrência, conforme se depreende do que restou apurado.

Nesta linha, já decidiu o STJ que,

“Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes” (RHC 94.061/SP, j. 19/04/2018).

Portanto, inobstante a atribuição constitucional da guarda municipal, autoriza-se a este efetivo do Poder Público a prisão daqueles que se encontrem em flagrante delito. Ademais, no caso, os guardas municipais estavam diante de uma situação de flagrante, havendo razão concreta para agir, na medida que presenciaram o réu, naquele exato momento, em atitude traficância. Daí, afasta-se a ilegalidade da prisão sustentada pela Defesa.

A materialidade delitiva se encontra consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 02/04, no auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, no laudo de constatação provisória de fls. 10/11, no laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 121/123, bem como na prova oral coligida.

A autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática criminosa, conforme depoimento das testemunhas, corroborados pela confissão em juízo pelo acusado.

Em solo policial (fl. 12), o acusado, sobre os fatos, permaneceu em silêncio.

Interrogado em juízo, o acusado confessou o delito. Disse que, por necessidades materiais de seus filhos, cometeu o crime.

Portanto, a pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, o guarda municipal Rodrigo Vettori, ouvido em delegacia à fl. 05, disse que “nesta tarde, realizava patrulhamento rotineiro com o seu companheiro de farda, estando a bordo de viaturas de duas rodas, quando decidiram acessar a Rua Rancharia, local bastante conhecido nos meios policiais devido à elevada incidência de crimes de tráfico ilegal de drogas, sendo que o próprio depoente já realizou prisões em flagrante nessa mesma rua. Assim que acessaram a via, notaram que havia dois indivíduos em atitude suspeita, eis que estavam parados e em pé, sendo que um deles trazia consigo uma sacola plástica nas mãos, o que sugeriu ao depoente que pudesse se tratar de um traficante de drogas. Assim que notaram a aproximação policial, os dois indivíduos correram por um escadão existente no local. Foram ao encalço daquele que trazia a sacola consigo, e conseguiram rapidamente abordá-lo, ocasião em que foi identificado como sendo JEFERSON DA LUZ THEODORO; o outro rapaz conseguiu se furtar à abordagem. No interior daquela sacola que o rapaz trazia consigo, verificaram que havia inúmeras porções individuais de drogas variadas, a saber: crack, cocaína e maconha, além de certa quantia em dinheiro trocado, cerca de R\$ 25,00. Indagado a respeito, JEFERSON admitiu de pronto que estava naquele local promovendo o tráfico ilegal de drogas, aduzindo inclusive que havia passado cerca de 6 anos encarcerado, cumprindo pena pela prática de dois crimes de tráfico ilegal de drogas, e que saiu recentemente da cadeia, estava promovendo o tráfico naquele local percebendo cerca de R\$ 300,00 ao dia. Acrescenta que na delegacia de polícia, ao ser submetido a uma revista minuciosa, foram encontrados mais R\$ 220,00, aproximadamente, na roupa íntima do suspeito”. No mesmo sentido foram as declarações do guarda municipal, e testemunha, Willian da Silva Dias, ouvido em solo policial à fl. 07.

O guarda municipal Rodrigo, sobre os fatos, respondeu que estavam em patrulhamento pelo local, logradouro já conhecido pela mercancia de entorpecentes. Quando adentraram a via em velocidade e puderam visualizar o acusado e outra pessoa; o réu portava uma sacola de cor preta; que ambos perceberam a presença da viatura e correram em direção de um escadão. Em seguida, conseguiram abordar o acusado e com ele ainda estava a sacola, na qual havia os entorpecentes apreendidos e uma quantia em dinheiro. Disse que havia maconha, crack e cocaína. Não conseguiram abordar a outra pessoa, que fugiu. No momento de sua prisão, o réu já confessou que praticava o crime e que o fazia por necessidades de seus filhos.

Por sua vez, o GCM Willian, corroborando as declarações de seu parceiro, em juízo, repetiu, integralmente, idênticas declarações prestadas pela testemunha Rodrigo.

Diante destes elementos de provas coletados em juízo, em observância às circunstâncias em que ocorreu a prisão do denunciado, tais situações, em conjunto revelam a prática incontestável do delito tipificado na denúncia consistente na prática do tráfico ilícito de drogas. A versão apresentada pelo acusado é corroborada com o conjunto probatório.

Com relação aos trechos dos depoimentos acima apontados, os quais foram prestados em juízo por guardas municipais, faz-se importante consignar que suas declarações devem ser apreciadas como as de qualquer cidadão, tanto que podem responder igualmente por falso testemunho.

Em razão disso, não se demonstrando que o funcionário público tenha mentido ou que exista fundado motivo para tanto, não há que se cogitar de inviabilidade de seu testemunho.

O depoimento testemunhal de servidores da força pública somente não terá valor se evidenciar que o funcionário do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstre que suas declarações não encontram suporte, licitude, legalidade e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios.

Sob este aspecto, verifico que os depoimentos coletados em juízo são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, inclusive, com a confissão do acusado, razão pela qual, à míngua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado em tese, afirma que “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL – I)

Não há dúvidas, ainda, que acerca da destinação dos entorpecentes encontrados com ele no momento de sua abordagem – quais sejam, 47 papérolas de maconha, pesando, aproximadamente, 132g; 170 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 153g e 90 pedras de crack, pesando, aproximadamente 23g, haja vista as circunstâncias da prisão, aliadas à natureza, diversidade e à quantidade de drogas que foram com ele apreendidas, comprovam, de maneira inequívoca, a finalidade mercantil. Como se não bastasse, o fato de ter sido apreendido o valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), que, ao ser considerado em conjunto com as circunstâncias já delineadas, demonstra, de maneira inequívoca, que tal valor era proveniente da mercancia ilícita de drogas.

Consigne-se que, para a caracterização da traficância, a jurisprudência é remansosa acerca da desnecessidade de identificação de qualquer suposto cliente para o qual a droga se destinaria, também não sendo necessário que os agentes sejam observados ou abordados enquanto praticassem atos efetivos de mercancia, muito embora as testemunhas visualizaram o acusado na efetiva prática de tráfico de drogas.

Neste interim, está sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, sendo curial destacar que, o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de “ter em depósito”, “guardar”, “transportar” e “trazer consigo”, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que, no caso dos autos, remanesce o flagrante crime de tráfico de drogas.

O acréscimo punitivo da agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea “j” do Código Penal, como requer o Ministério Público, no caso concreto, é injustificável, na medida em que não relacionado com o maior desvalor da conduta. Não há nos autos prova no sentido de que o réu tenha efetivamente se valido das fragilidades ocasionadas pela pandemia para delinquir, sob pena de responsabilização objetiva. Portanto, inexistente qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública, despropositada sua aplicação.

Por estarem comprovadas, portanto, autoria e materialidade delitivas, bem como o fato de que as substâncias entorpecentes apreendidas em sua posse tinham destinação mercantil, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Passo à aplicação da pena.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ligada tanto às particularidades fáticas do caso concreto quanto às especificidades subjetivas dos agentes. No crime de tráfico de drogas, a expressa dicção legal do artigo 42 da lei 11.343/2006 determina ao juiz, quando da fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código

Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, que podem permitir o aumento da pena-base do condenado.

Atendendo às disposições constantes do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, bem como ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, verifico que o acusado ostenta duas sentenças condenatórias transitadas em julgado (certidão de fls. 82/84), sendo que uma será relevada como reincidência, na fase própria da dosimetria da pena, e a outra relevada como maus antecedentes do acusado. A quantidade das drogas apreendidas em seu poder, por seu turno, não habilita a majoração da pena-base. Assim, ante seus maus antecedentes, majoro a pena-base acima do mínimo legal, e fixo-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, este juízo entende que a agravante da reincidência deve ser minorada em face do reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, de modo que agravo a pena em 1/12 avos, atingindo o patamar de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 677 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA. Cumpre consignar que este juízo não entende ser possível a compensação da agravante da reincidência pela atenuante da confissão espontânea, tendo-se em vista que a reincidência é circunstância preponderante à confissão espontânea, com fulcro no artigo 67, do Código Penal. Por oportuno, que o acusado não faz jus à diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, por ser reincidente.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal e no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, uma vez que, embora a pena fixada não seja superior a oito anos, tal regime é o único recomendável ao caso dos autos, ante a elevada culpabilidade de agentes que cometem tráfico ilícito de entorpecentes, e se encontra em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (artigo 5º, inciso XLIII), não se podendo olvidar, aliás, que o acusado é reincidente.

Ainda, atendendo a nova redação do art. 387, § 2º, CPP, dada pela lei 12.736/12, mantenho o regime FECHADO, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo vigente no dia do fato, corrigido em sede e executado em sede de execução, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º e 51, ambos do Código Penal, por não haver provas nos autos de que o réu possuía boa situação financeira.

É incabível o sursis, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante a reincidência do réu.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para o fim de CONDENAR o acusado

JEEFERSON DA LUZ THEODORO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO, no regime inicial FECHADO, vedadas quaisquer substituições previstas em Lei, bem como à pena de 677 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, e com o artigo 65, inciso III, "d", ambos do Código Penal.

O réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual, o que demonstra que subsistem os requisitos da prisão preventiva, máxime agora, com sentença penal condenatória, não havendo, pois, quaisquer motivos para a concessão de liberdade provisória em seu favor, pelo que não poderá apelar em liberdade.

Nesse sentido:

"É pacífico na jurisprudência que o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se aplica ao réu já preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal, ou pelo menos grande parte dele.

Confira-se, a respeito, o posicionamento desta C. Câmara, ao decidir questões semelhantes:

'Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada.' (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

'HABEAS CORPUS - Tráfico de Entorpecentes - Regime inicial fechado - Fixado de acordo com a legislação vigente - Apelo em liberdade vedado - Réu que permaneceu preso durante o processo - Não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência - Ordem denegada.' (HC nº 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.).

O C. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito, afirmando: 'A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.' (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão. Assim, não se caracteriza, aqui, medida desproporcional que revele o alegado constrangimento do paciente."

(Habeas Corpus nº 2055783-89.2013.8.26.0000 - 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator De Paula Santos - julgado em 27 de março de 2014 - votação unânime).

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso, comunicando-se a alteração da natureza de sua custódia.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que nesta oportunidade lhe concedo os benefícios da gratuidade da justiça, em razão de ter sido defendido pela Defensoria Pública no presente feito.

Por se tratar de proventos auferidos com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, determino o perdimento dos valores apreendidos nos presentes autos, nos termos do artigo 63 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06. Oficie-se à autoridade policial para a destinação cabível, nos termos do artigo 516, das NSCGJ.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06).

P.I.C.

Franco da Rocha, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA